

1517412-64.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517412-64.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517412-64.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203291/2020 - 95º D.P.

HELIÓPOLIS, 13064573 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 1429/20/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS,
2203291 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FONTENELE VASCONCELOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

THIAGO FONTENELE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na tarde de 18 de agosto de 2020, por volta das 13h45min, na Rua Jose das Neves Santos, nº 156, bairro Sacomã, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, em ocasião de calamidade pública, seis porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a acusação, o crime foi praticado em ocasião de calamidade pública, em

razão da pandemia provocada pelo Covid-19 na cidade de São Paulo.

Consta da denúncia que segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis encontraram a droga supramencionada na posse do denunciado, que trazia para venda a terceiros.

Relata a inicial que de acordo com as investigações, os policiais civis abordaram o denunciado e encontraram na posse dele uma porção de maconha. O denunciado confessou a prática delitiva para os agentes, afirmando que no interior de um carro estacionado perto do local dos fatos haveria mais porções da droga. Os policiais foram até o local indicado e, ali, acharam mais cinco porções de maconha dentro do automóvel.

Narra a exordial que diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado até o Distrito Policial. Realizado interrogatório, ele optou por negar a prática delitiva (fl. 19).

Por decisão exarada em 19 de agosto de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 53/55).

A Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus com pedido liminar, visando, em suma, a revogação da prisão preventiva e o deferimento de sua liberdade provisória (fls. 66/84).

A medida liminar pretendida pelo writ foi deferida parcialmente, para revogar a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado e, concomitantemente, para impor algumas medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 85/91 e 109).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de janeiro de 2021 (fl. 112).

O acusado foi citado pessoalmente (fls. 119/120).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a sua absolvição sumária (fl. 125).

Aos 26 de setembro de 2021, o recebimento da denúncia foi ratificado e foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 23 de março de 2022 (fls. 126/127).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois o réu negou a prática do delito, afirmando ser mero usuário de drogas, em versão que não foi refutada pelas demais testemunhas de acusação; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; e) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; f) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor. Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 06 e 14), Boletim de ocorrência (fls. 07/09), Auto de exibição e apreensão (fl. 13), Laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/118) – cujo resultado é positivo para a presença da substância tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha – bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Nikson Jorge Castro Lima, policial civil, narrou, em síntese, que lembra do Réu presente em audiência. Estavam em diligências para combater o tráfico e foram a local conhecido, fizeram breve observação do acusado e algumas pessoas se aproximaram dele. Os supostos compradores conseguiram se evadir e em revista no réu encontraram uma porção de maconha. O réu indicou que o restante da droga estaria em uma sacola no interior de um carro abandonado. O réu disse que estaria ali a pedido de um amigo, mas não quis declinar o nome do amigo. Foram até o carro, não se recorda que carro era, era um carro abandonado. No interior do carro encontraram uma sacola com mais cinco porções de maconha. Também foi ouvida em juízo a testemunha Ricardo de Castro, policial civil, que narrou, em suma, que se lembra do Réu. Estavam em operação de combate ao tráfico e o local era ponto conhecido de venda de entorpecentes. Fizeram breve campanha e as pessoas se aproximavam, conversavam e após alguns minutos de campanha, optaram pela abordagem. Na abordagem o réu disse que o amigo precisou sair e ele ficou ali cobrindo o lugar do amigo. O réu tinha droga e a maioria estava em um carro. O réu apontou o veículo. A droga era maconha e cocaína. Tinha pequena quantia em dinheiro com o réu.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou que está com 35 anos de idade. Está trabalhando ajudando na loja de artigos religiosos e também em uma ONG. Mora com a ex-esposa. Estudou até a oitava série. Na época estava morando naquele ambiente e no dia estava brincando com a cachorra na rua e a rua é sem saída, os “caras” usam para tráfico de drogas. Eram duas outras pessoas que foram até ali e os “caras” correram. Os policiais algemaram o interrogando. Tiraram menores de dentro do carro. Como eles tinham achado uma única porção de maconha, atrás do veículo Santana, encontraram 5 porções de maconha, dentro de um saco cinza. Eles queriam que pagasse R\$ 5.000,00 para ser solto. O interrogando estava com uma porção de maconha, porque na época era usuário de maconha. Não tinha dinheiro naquele dia. Viu o policial pegar o dinheiro de um dos meninos que estava ali fazendo uso de droga. Nunca tinha visto os policiais antes.

Ocorre que, diante da prova oral colhida em juízo, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos que não sejam em torno do principal não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos

policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha); b) pela quantidade de porções; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em porções); d) pela apreensão de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo e tinha em depósito as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido crime em ocasião de calamidade pública).

Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos."

(Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 31/33) e da Certidão (fl. 37). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei

que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem qualquer antecedente, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010).

(grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado THIAGO FONTENELE VASCONCELOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/2006, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 20,00), em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA